

1501242-10.2022.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Willi Lucarelli

Comarca: Embu-Guaçu

Foro: Foro de Embu-Guaçu

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITOS DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MATÉRIAS ANTERIORMENTE APRECIADAS PELA CORTE SUPERIOR EM HABEAS CORPUS CONEXO. REITERAÇÃO COM IDÊNTICOS FUNDAMENTOS E PEDIDO NO RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE. TRÁFICO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu-Guaçu

Foro de Embu-Guaçu

Vara Única

Rua Boa Vista nº 10, Embu-Guacu-SP - cep 06900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501242-10.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501242-10.2022.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2181468/2022 - DEL.POL.EMBU-GUAÇU, 25955040 -

DEL.POL.EMBU-GUAÇU, 2181468 - DEL.POL.EMBU-GUAÇU

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Willi Lucarelli

VISTOS.

LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA, TIAGO CESAR RODRIGUES DA SILVA e THIAGO MARTINS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 05 de julho de 2022, à tarde, no endereço descrito com a inicial, os denunciados guardavam, para entrega ao consumo de terceiros, 68 porções de cocaína, 03 porções de maconha e 11 pedras de crack, em desacordo com determinação legal.

Processada, a denúncia fora recebida. Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e, ao final, os réus foram interrogados.

O Ministério Público apresentou alegações finais durante a audiência, pugnando pela condenação dos réus, com a cominação, contudo, apenas ao réu LUCAS do regime inicial fechado.

A Defesa do réu THIAGO MARTINS apresentou alegações finais durante a audiência, pugnando, em resumo, pela absolvição do réu, por não haver cometido qualquer delito.

A Defesa do réu LUCAS RODRIGUES apresentou alegações finais durante a audiência, pugnando, em resumo, pelo reconhecimento da confissão espontânea, com a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, com a substituição da pena então computada por restritiva de direitos.

A Defesa do réu TIAGO CESAR apresentou alegações finais escritas, pugnando pela absolvição do réu, por falta de provas ou, alternativamente, a desclassificação para o crime de porte ilegal de drogas. Subsidiariamente, requer a cominação da pena no mínimo legal, com a substituição da pena então computada, sendo reconhecido o direito de o réu apelar em liberdade.

DECIDO.

Cumpre reconhecer que, na análise da pretensão punitiva deduzida, a ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 15/17), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 20/21), pelo laudo toxicológico (fls. 115/117) e pela prova oral colhida.

Da mesma forma, diversamente do que afirmado pela combativa defesa, a prova vinda aos autos demonstrou, à saciedade, a responsabilidade criminal dos réus, servindo, assim, de fundamento para o presente decreto condenatório.

É certo que o réu THIAGO MARTINS, na fase judicial, negou o ocorrido, alegando, em síntese, que foi comprar comida para o traficante, que tinha se negado a vender-lhe drogas fiado, em troca de uma pedra de crack.

O denunciado afirmou que não ficou de olheiro e, ainda, não poderia vender entorpecentes, tendo confirmado que comprou para o traficante, chamado LUCAS, um salgado e um refrigerante na padaria.

O réu falou, também, que não conseguiu avisar sobre a chegada dos agentes públicos e que o GCM deu uma rasteira no LUCAS, tendo escutado "aí, não precisa fazer isto", acrescentando, ademais, que o agente público estava com uma madeira "perto da gente", tendo dado "rasteira e ficou em cima do braço, enquanto ele estava algemado."

Igualmente, o réu TIAGO CESAR negou o ocorrido, dizendo, na fase judicial, que foi adquirir drogas de LUCAS, sendo certo que, na medida em que não aceitou fiado, "nos oferecemos para buscar alimentos", de modo que, ao retornar, "ele deu mais uma."

O denunciado falou, ainda, que "ele falou para a gente olhar", no entanto, antes de terminar de usar a droga, os agentes públicos chegaram ao local, tendo esclarecido que ficou olhando por dez minutos.

O réu mencionou, também, que LUCAS correu quando os agentes públicos chegaram, sendo que "o policial derrubou e ele caiu sobre o braço, ele estava detido, não foi durante a perseguição policial", tendo descrito que "GCM's que agrediram era o moreninho fortinho".

Contudo, as suas alegações não encontram amparo na prova oral colhida nos autos, que foi firme e segura em confirmar todo o desenrolar fático apontado pela denúncia.

Nesse sentido, o guarda municipal CLAUDIO FRANCISCO, na fase judicial, disse que, durante patrulhamento de rotina, se deparou com dois indivíduos em atitude suspeita, sendo certo que nada de ilícito foi encontrado, no entanto, o réu LUCAS, que estava escondido no mato, correu e acabou por ser alcançado.

O agente público afirmou, ainda, que, em seguida, “ele caiu sobre o próprio braço”, tendo dito, também, que os dois indivíduos disseram que estavam no local “como olheiros”.

Por fim, o guarda municipal afirmou que o réu LUCAS confessou, dizendo que os demais denunciados iriam receber em pedras de crack, tendo, ademais, indicado o local onde os entorpecentes foram localizados.

Da mesma forma, foram as declarações do guarda municipal MALCO na fase judicial, esclarecendo, também, que “LUCAS correu logo após”.

Na fase policial, os guardas municipais trouxeram idêntica versão para os fatos.

A esse respeito, deve-se destacar que o guarda municipal CLAUDIO FRANCISCO afirmou que, após a abordagem de THIAGO MARTINS e TIAGO CESAR, visualizou o réu LUCAS cerca de três metros para baixo, em um matagal, sendo certo que tentou se evadir “e o mesmo escorregou e caiu em cima de seu próprio braço” (fls. 08).

Não há provas que tenham o condão de desconstituir a presunção de legitimidade do ato praticado pelos guardas municipais, de modo a indicar que a diligência policial foi perpetrada em função de interesses escusos.

Realmente, não se nega que, por vezes, haja desvios de finalidade na prática de atos administrativos, infelizmente, movidos por interesses que não se compatibilizam com as funções precípua do Estado, mas não parece ser o caso dos autos.

É que não seria razoável que os guardas municipais tivessem apreendido drogas, mais dinheiro e falsamente imputassem a indivíduos que sequer tinham qualquer rixa ou desentendimento.

Ainda mais, quando se considera que o denunciado LUCAS confessou, na fase judicial, os fatos, afirmando que fazia dois ou três meses que atuava para o tráfico de drogas, de modo que recebia R\$ 600,00 por dia.

O réu LUCAS confirmou que os denunciados foram buscar comida, em troca de drogas (uma pedra de crack), sendo certo que, enquanto comia, os denunciados THIAGO e TIAGO “ficaram olhando”, por cerca de dez minutos.

Acerca da alegação do réu de que os GCM's agrediram o réu LUCAS, cabe salientar que a questão carece de provas mais concretas, devendo-se destacar, também, que o exame de corpo de delito identificou a ocorrência de fratura no punho direito do denunciado LUCAS (fls. 81), lesão que não se compatibiliza com a natureza das agressões descritas pelo denunciado.

É que o réu LUCAS disse ao perito judicial que caiu da própria altura após um chute (fls. 81), cabendo destacar que, na fase judicial, o réu afirmou que foi agredido na região do joelho com uma madeirada, após ter sido pego pelo braço. A mesma menção à madeira foi feita pelo acusado THIAGO MARTINS na fase judicial. Por sua

vez, durante a audiência de custódia, o réu LUCAS afirmou que quebrou o punho, após sofrer uma rasteira do agente público (fls. 102).

Ocorre que nenhuma lesão foi identificada como decorrente do apontado chute, da rasteira ou, ainda, na região do joelho do acusado LUCAS, sendo certo que seria absolutamente crível que assim se exigisse, principalmente quando se considera que o denunciado LUCAS mencionou que foi agredido com uma madeira.

Em acréscimo, não se pode desconsiderar que ao Delegado de Polícia o denunciado LUCAS disse que chegou a escorregar e cair sobre o próprio braço (fls. 09), não sendo crível que tivesse sido ameaçado por terceiros para criar esta versão, sem que o Delegado de Polícia tivesse percebido, tal como descreveu na fase judicial.

O próprio MM. Juízo da Custódia ficou com a mesma impressão, tanto é que consignou em sua r. decisão que “no que toca à aventada agressão policial sofrida por Lucas, quando da sua prisão em flagrante, tenho que o relato dos guardas civis e a dinâmica dos fatos justifica a lesão no braço. Não vislumbro, pois, nenhuma evidência de abuso ou ilegalidade que justifique pronta instauração de procedimento apurativo em desfavor dos guardas civis (...).” (fls. 85).

Na verdade, muito provavelmente, a fratura identificada deve estar relacionada à dinâmica da diligência, ainda mais considerando a mencionada tentativa de fuga do denunciado, tal como narrou o guarda municipal CLAUDIO FRANCISCO na fase judicial.

Portanto, no caso em exame, tenho por justificada a lesão constatada.

Em suma, a diligência enquadra-se na grande maioria dos atos administrativos, ou seja, daqueles realizados de forma legítima e segundo os ditames da boa-fé.

Ademais, mister salientar que não há qualquer ilegalidade na atuação da Guarda Municipal no caso dos autos, porquanto se tratou de situação de flagrante delito, que se revela cabível, diante do teor do artigo 301 do Código de Processo Penal.

De fato, dispõe o artigo 144 da Constituição Federal que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio de diversos órgãos.

A atribuição da guarda municipal insere-se nesse contexto, não só para fins de patrulhamento preventivo, como também para o uso progressivo da força, conforme disposto no artigo 3º, incisos III e V, da Lei Federal nº 13.022/2014, cabendo-lhe também “colaborar, de forma integrada, com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social” e “encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração” nos termos previstos no artigo 5º, IV e XIV, da citada legislação.

Em acréscimo, cabe destacar que não era necessária qualquer investigação prévia por parte dos agentes municipais, que estavam realizando ronda por local notoriamente conhecido pelo comércio de drogas, quando avistaram os denunciados TIAGO CESAR e THIAGO MARTINS em atitude suspeita.

No mais, a revista pessoal está expressamente autorizada nos artigos 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, quando há fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, independentemente, de ordem judicial.

Na hipótese vertente, como já destacado, os agentes públicos estavam em local conhecido pela mercancia de entorpecentes e os denunciados apresentaram atitude manifestamente suspeita, justificando a atuação da Guarda Municipal, cabendo

acrescentar que, ao final, a percepção dos guardas municipais mostrou-se absolutamente correta.

Seguindo essa linha de entendimento, confira-se o seguinte julgado da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE PELA ATUAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE LEGITIMAM A AUTUAÇÃO DA REFERIDA ENTIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 301 DO CPP. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA BASILAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.

II - Inicialmente, no que se refere à pretensão de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, verifico tratar-se de inovação recursal em sede de agravo regimental, uma vez que tal pretensão não foi feita na inicial do writ, o que não é admitido pela jurisprudência. Ademais, ainda que assim não fosse, a reincidência do agravante obsta a concessão da benesse, não havendo que se falar em bis in idem. Precedentes.

III - No que se refere à preliminar de nulidade pela atuação da guarda municipal, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para refutar a referida alegação que estão em sintonia com o entendimento deste Tribunal que, embora ressalte ser descabida a realização de investigações de práticas de ilícitos, disso não se desume a possibilidade de, mediante notícia de crime, proceder a diligências de averiguação, haja vista a possibilidade de prisão em flagrante, como ocorreu no presente caso. Com efeito, como bem observado pela Corte de origem, "os Guardas Municipais, assim como qualquer outra pessoa do povo, ao contrário do entendido externado pela nobre Defesa, pode deter alguém pela prática de crime, desde que em flagrante delito" (fl. 88), não havendo que se falar em nulidade por este fundamento. Precedentes.

IV - Outrossim, descabida a alegação de que a basilar foi aumentada de forma inidônea, haja vista que a sentença condenatória levou em consideração a natureza, quantidade e diversidade das drogas apreendidas, tratando-se de "04 porções de maconha, com peso líquido de 0,74g; 50 porções de maconha, com peso líquido de 105,98g; 23 porções de cocaína, com peso líquido de 11,93g; 23 porções de cocaína, com peso líquido de 15,2g; e 31 porções de cocaína sob a forma de crack, com peso líquido de 5,02g" (fl. 46), aplicando a fração de 1/6 (um sexto), tudo de acordo com o entendimento deste Tribunal. Precedentes.

V - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 748.762/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.)."

Nesse panorama, é indiscutível a veracidade dos fatos articulados na denúncia, constituindo a conduta afronta ao artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, eis que presentes a autoria, a materialidade, o dolo específico e a tipicidade da conduta.

Além do mais, inexistente qualquer influência no fato de os réus TIAGO CESAR e THIAGO MARTINS terem atuado na condição de olheiros, seja para permitir que o denunciado LUCAS se alimentasse, seja para trocar por drogas.

É que o tipo previsto no artigo 33 da Lei de Drogas não pressupõe, necessariamente, a prática de atos onerosos, ou de comercialização, bastando a vontade livre e consciente de perpetrar qualquer dos verbos do tipo penal, côncio, o agente, que

atua sem autorização legal, ou regulamentar, o que efetivamente ocorreu.

Por fim, não há margem para a desclassificação da conduta dos réus TIAGO CESAR e THIAGO MARTINS para o crime de porte ilegal de drogas ou, ainda, sejam as condutas consideradas como participação de menor importância.

É que ambos os réus afirmaram, na fase judicial, que permaneceram por dez minutos, seja a espera de atendimento, como afirmou THIAGO MARTINS, seja como "olheiro", como disse expressamente o réu TIAGO CESAR.

Ora, o lapso temporal decorrido afigura-se mais do que suficiente para configurar, no mínimo, o verbo guardar descrito no tipo penal e na denúncia, cabendo considerar, ainda, que o tipo penal neste ponto não exige prova da venda dos entorpecentes.

Relativamente à apontada participação de menor importância, cabe salientar que aquele que exerce a função de olheiro colabora, de forma eficaz, para a difusão e incentivo ao tráfico de drogas, porquanto a conduta tem a finalidade de assegurar maior tranquilidade e eficiência do vendedor, aumentando, inclusive, a fora da atividade criminosa. Portanto, fica desacolhida a alegação.

Em suma, sob todos os ângulos analisados, existem provas mais do que suficientes para a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas, razão por que passo a dosar as penas:

DO RÉU TIAGO CESAR RODRIGUES DA SILVA;

Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a pena-base deve ser fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, no mínimo legal.

Na segunda fase de aplicação da pena, deixo de considerar eventual confissão espontânea, pois a pena, de toda forma, ficaria abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase de aplicação da pena, diante da concordância do Ministério Público (fls. 192/193), reconheço a existência da causa de diminuição e fixo o redutor em seu patamar máximo, totalizando a pena o montante de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Por conseguinte, a pena fica substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em: a) prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena, em substituição a ser indicada pelo juízo das execuções criminais, descontado o tempo cumprido de prisão cautelar; b) prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, a entidade com destinação social, a ser definida pelo juízo das execuções criminais.

Em caso de descumprimento, o regime inicial de cumprimento de pena será o aberto.

O réu poderá apelar em liberdade, diante da substituição da pena cominada.

DO RÉU THIAGO MARTINS;

Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a pena-base deve ser fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, no mínimo legal.

Na segunda fase de aplicação da pena, deixo de considerar eventual confissão espontânea, pois a pena, de toda forma, ficaria abaixo do mínimo legal.

Para todos os efeitos, deixo de considerar negativamente qualquer passagem criminal do réu no Estado do Paraná, eis que, além de ter afirmado ter sido absolvido, após

determinação verbal deste julgador, a serventia não identificou qualquer condenação, após consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça Paranaense.

Na terceira fase de aplicação da pena, diante da concordância do Ministério Público (fls. 192/193), reconheço a existência da causa de diminuição e fixo o redutor em seu patamar máximo, totalizando a pena o montante de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Por conseguinte, a pena fica substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em: a) prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena, em instituição a ser indicada pelo juízo das execuções criminais, descontado o tempo cumprido de prisão cautelar; b) prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, a entidade com destinação social, a ser definida pelo juízo das execuções criminais.

Em caso de descumprimento, o regime inicial de cumprimento de pena será o aberto.

O réu poderá apelar em liberdade, diante da substituição da pena cominada.

DO RÉU LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA;

Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a pena-base deve ser fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 1/6 acima do mínimo legal.

Justifica-se a exasperação, em função dos maus antecedentes do réu, que foi condenado, com trânsito em julgado, nos autos do Processo n.º 1500850-07.2021 (fls. 191), não havendo qualquer influência no fato de o trânsito em julgado ter se operado após a data dos presentes fatos.

A esse respeito, passo a indicar o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no HC n. 607.497/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 30/9/2020.

Na segunda fase de aplicação da pena, a pena retornará ao mínimo legal, diante da confissão espontânea do réu.

Na terceira fase de aplicação da pena, deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, eis que a aplicação do dispositivo demanda o preenchimento cumulativo de seus requisitos, desde que associados às circunstâncias do artigo 42 da Lei de Drogas.

No presente caso, o réu guardava drogas dos mais diversos tipos para entrega a terceiros, tendo sido apreendida razoável quantidade de dinheiro (fls. 20 - R\$ 342,65), sendo que estas peculiaridades, aliadas à confissão do réu e, ainda, à sua condenação, com trânsito em julgado, pelo crime de tráfico de drogas Processo n.º 1500850-07.2021 (fls. 191), permitem a conclusão de que não se trata de traficante não habitual.

Sobre a reincidência ou os maus antecedentes como motivação idônea para a negativa à aplicação da causa de diminuição, confira-se o seguinte julgado:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITOS DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MATÉRIAS ANTERIORMENTE APRECIADAS PELA CORTE SUPERIOR EM HABEAS CORPUS CONEXO. REITERAÇÃO COM IDÊNTICOS FUNDAMENTOS E PEDIDO NO RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º DA LEI N. 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS. NÃO PREENCHIMENTO.

NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

2. É cediço na jurisprudência desta Corte Superior que a análise anterior das matérias objeto do recurso especial nos autos de habeas corpus impetrado com idênticos fundamentos e pedidos implica perda de interesse recursal e prejudicialidade da pretensão recursal. Precedentes.

3. Na espécie, os pleitos atinentes à desproporcionalidade do quantum incrementado à pena-base e ao abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena foram anteriormente apreciados por este Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 672.615/SP, impetrado pela mesma parte, contra o mesmo acórdão, sob os mesmos fundamentos e com os mesmos pedidos. Assim, inafastável o reconhecimento da prejudicialidade do recurso especial, nos pontos.

4. Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto.

5. In casu, consoante asseverado pelas instâncias ordinárias, o recorrente ostenta múltiplas condenações anteriores, também por tráfico de drogas, configuradoras de maus antecedentes (e-STJ fls. 465 e 609) - o que, por si só, constitui fundamentação idônea para afastar a benesse pleiteada, ante o não preenchimento de um dos requisitos legais cumulativos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n.

11.343/2006 -, além de ter sido preso em flagrante delito por transportar e guardar, para fins de tráfico, 163,480kg de cocaína (e-STJ fl. 602). Nesse contexto, inviável a aplicação da privilegiadora postulada.

6. Agravo regimental não provido. (grifo nosso).

(AgRg no REsp 1970177/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)."

Portanto, sob todos os ângulos analisados, o réu não faz jus à causa de diminuição.

Sendo assim, torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e, nos termos do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, fixo em 500 (quinhentos) dias-multa, a razão de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente, a contar da mesma data.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, considerando as provas de que se dedicava a atividades criminosas, de modo que a imposição de regime menos rigoroso não surtirá qualquer efeito.

Neste sentido, confira-se o seguinte julgado, consoante aresto que passo a transcrever:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há como aplicar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando verificado que a Corte de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontou elementos concretos dos autos que evidenciam a dedicação do acusado a atividades criminosas.

2. As peculiaridades do caso concreto (quantidade e natureza da droga, bem como a dedicação do acusado ao narcotráfico) justificam a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda aplicada.

3. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.



4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 566.498/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)."

Não havendo qualquer influência o tempo de pena provisória cumprida, para fins de detração penal, porquanto ofensiva ao princípio do juiz natural e da individualização da pena.

O réu não poderá apelar em liberdade.

Não se nega que, em função da cautelaridade da prisão provisória, o pedido deve ser juridicamente possível, ou seja, não deve encontrar obstáculo em qualquer das vedações legais previstas na Lei n.º 12.403/11.

Contudo, no caso em exame, houve decreto de prisão preventiva (fls. 83/85), que esteve a considerar todas estas circunstâncias legais e fáticas, em decisão não impugnada pela Defesa.

E, neste meio tempo, nada houve que tivesse o condão de apontar a existência de fatos novos, inclusive jurídicos, senão aqueles que subsidiaram a r. decisão lançada.

Sendo assim, ainda mais agora que todo o contexto probatório está a indicar ter sido o réu autor do delito, nada há que esteja a justificar nova apreciação do pedido, sob pena de, por via transversa, desfazer-se situação jurídica consolidada e suprimir instância judicial.

Assim, sob todos os ângulos analisados, não há qualquer constrangimento ilegal que esteja sendo imposto à liberdade de locomoção do réu, sendo de rigor a manutenção da medida.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, CONDENO LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, À PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, a ser cumprida inicialmente em REGIME FECHADO, e 500 dias-multa, a razão de 1/30 do salário-mínimo na data dos fatos, corrigido monetariamente, a contar da mesma data, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

CONDENO TIAGO CESAR RODRIGUES DA SILVA e THIAGO MARTINS, qualificados nos autos, À PENA DE 01 (UM) ANO e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, que fica SUBSTITUÍDA, na forma acima determinada, e 500 dias-multa, a razão de 1/30 do salário-mínimo na data dos fatos, corrigido monetariamente, a contar da mesma data, como incursos no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Por conseguinte, expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de TIAGO CESAR RODRIGUES DA SILVA e THIAGO MARTINS.

DECRETO a perda, em favor do Estado de todos os bens apreendidos, nos termos do artigo 63 da Lei n.º 11.343/06.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome dos condenados no rol dos culpados. Custas na forma da lei.

Registre-se e comunique-se, com as anotações de estilo.

Embu-Guacu, 20 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA